

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 6a Nominación de Córdoba

Renella, Héctor E. c. Vázquez, Elsa A. • 03/03/2004

2ª Instancia. - Córdoba, marzo 3 de 2004.

El Tribunal planteó las siguientes cuestiones para resolver: 1º) ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada? 2º) En su caso, ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión. - El doctor Lavayen dijo:

La sentencia dictada en primera instancia contiene una relación de causa que satisface plenamente las exigencias del art. 329 del CPC, por lo que a ella me remito a fin de evitar inútiles e innecesarias repeticiones.

II) El pronunciamiento que decide hacer lugar a la excepción de prescripción adquisitiva y, en consecuencia, rechaza la demanda de reivindicación, es apelado por la parte actora, que, manifiestan ante la alzada, en memorial que luce a fs. 292/303, las razones de su disconformidad con el fallo.

A fs. 306/312, contesta los agravios la parte demandada y, a base de las argumentaciones que expresa pide el rechazo de la apelación, con costas, y adhiere al recurso de apelación deducido por la actora, expresando los agravios que le provoca la resolución en crisis (fs. 313/315).

III) Agravios de la parte actora: Primer Agravio:

En primer lugar, resiste el pronunciamiento en cuanto asevera que "... la invocación que efectúa el actor en sus alegatos respecto que el art. 2790 hace presumir que se le ha transmitido la posesión del bien, resulta irrelevante en el sublite puesto que, como surge del texto legal, se trata de una presunción y que en el presente caso ha sido rebatida ampliamente a tenor de las probanzas arrojadas, inclusive el propio reconocimiento que formula el actor acerca de que la demandada es poseedora (aunque sea de mala fe)...". Dice que, cuando el art. 2790 se refiere al título, se entiende que es la causa en la que funda el derecho de dominio del reivindicante; por eso la doctrina y jurisprudencia son contestes en afirmar que el reivindicante con título no necesita probar que ha tenido la posesión. A su entender, la a quo no subsume en forma correcta el art. 2790 C.C. La resolución impugnada, al establecer que el actor se refiere a la norma citada presumiendo se le ha transmitido la posesión del bien, no subsume correctamente el caso de autos en esa disposición ya que, precisamente, ejerce la acción reivindicativa porque no tiene la posesión y

no es necesaria la transmisión de la posesión cuando el reivindicante invoca la de sus antecedentes.

Que el reivindicante tuvo la posesión del bien es una presunción iuris tantum que, para ser destruida por la demandada, requiere se pruebe que ninguno de los antecesores del demandante, y no solamente el inmediato, tuvo nunca la posesión de la cosa. Además, tiene que presumirse que los antecesores del reivindicante tuvieron la posesión de la cosa desde la fecha de su título con arreglo a la doctrina de los arts. 2790 y 4003 C.C., presunción que, a su parecer, no fue destruida por prueba en contrario, razón por lo cual, corresponde su aplicación ya que el actor presentó título suficiente, es decir, la causa o motivo por el que es propietario inscripción de la compra de la subasta en el Registro Gral. de Propiedad), valiéndose de sus antecesores. Además -agrega- la demandada no ha probado que los antecesores en el título presentado por el actor no detentaron la posesión.

Se agravia por cuanto la sentencia considera irrelevante el art. 2790 ib. en el caso sub-examine, pues otorga mayor validez a una fotocopia de un boleto de compraventa -sin autenticación y fecha cierta- y una declaración testimonial, que si bien ocurrió no puede corroborarse al carecer de su texto íntegro, que a un instrumento público como es la escritura traslativa entre el Sr. Fombella y el Sr. Sanmartino.

Dice que el boleto de compraventa de fs. 20 en que se funda la sentencia carece de todo valor probatorio por ser una simple fotocopia, no reconocida, sin fecha cierta, que no es título traslativo de propiedad por lo que tampoco la demandada puede poseer desde esa fecha.

Señala que la compra realizada en subasta respecto a los derechos y acciones de la Sra. Cangiano es justo título porque ella adquirió por escritura pública de donación del Sr. Sanmartino y éste había adquirido los derechos y acciones por cesión de su padre en escritura, a Fombella. Considera que dicho título del actor es justo y suficiente para reivindicar, no pudiendo oponerse a esta acción la demandada fundada en una fotocopia de un boleto de compraventa que carece de fecha cierta y autenticidad.

Dice que el boleto presentado por la demandada no es justo título para prescribir y, como la sentencia le otorga mayor eficacia que a una escritura pública, vulnera las disposiciones legales mencionadas, por lo que debe dejarse sin efecto.

Se agravia, también, porque la sentencia establece que "... la Sra. Vázquez ejerce la posesión del inmueble objeto de autos con intención de tenerlo para sí, en forma legítima, pública, pacífica e ininterrumpida desde septiembre del año 1982..." lo que no es cierto y perjudica a su parte, porque la demandada no puede cambiar por

si y su voluntad, la causa de su posesión conforme lo disponen los arts. 2353 y 2354 C.C.

Alega que la demandada habitó el inmueble como conviviente del Sr. Sanmartino, reconociendo en este al poseedor, ya que la escritura pública del 15/10/82 le otorgó a él la posesión y no a ella, por lo que era tenedora del inmueble, pues, la fotocopia del boleto de compraventa presentado es un instrumento privado, carente de autenticidad y fecha cierta, y no puede prevalecer sobre un instrumento público.

De esta manera, sostiene que la demandada, a partir del 15/10/82, por el conocimiento que tuvo de la escritura labrada a favor del Sr. Alfredo Orlando Sanmartino -ya que estuvo presente en el acto notarial donde se le otorgó la posesión del inmueble- reconocía en él, al detentador de la posesión y fue tenedora del bien.

Concluye, entonces, que de acuerdo con el art. 2353 C.C. la Sra. Vázquez no pudo por su propia voluntad cambiar la causa de la posesión, que es el antecedente jurídico que engendró su derecho (escritura pública), la que continuó siempre (art. 2354) como tenedora.

Resiste la sentencia en cuanto establece que la demandada ejerce la posesión del inmueble "en forma legítima", pública, pacífica e ininterrumpida, con intención de

tenerlo para sí desde septiembre de 1982. No es legítima al violar abiertamente los arts. 2353 y 2354 pues el 15/10/82 conocía que el poseedor era el Sr. Alfredo O. Sanmartino; tampoco es pública ya que recién en el proceso de desalojo "Sanmartino c/ Vázquez", sent. del 12/11/87 invocó que poseía para si misma ocultándola hasta esa fecha cinco años después; no fue pacífica, ya que soportó dos procesos de desalojo; y no fue ininterrumpida ya que ella conoció que Fombella le vendió al Sr. Sanmartino.

Segundo Agravio: Manifiesta que la resolución impugnada se fundamenta en la afirmación de que la demandada ejerció la posesión del inmueble desde el 20/09/82, por la declaración del Sr. Edgard Ignacio Fombella, anterior titular registral del bien, quien según la demandada, afirmó haber entregado la posesión en forma voluntaria a ella en esa fecha, lo que no ha sido verificado en esta causa.

Dice que, por el principio de bilateralidad, la doctrina enseña que la prueba testimonial practicada en otro proceso en el cual no fueron partes los mismos sujetos, para poder ser trasladada, es necesario que sea ratificada por el testigo, de lo contrario es ineficaz, lo que sucede en la especie toda vez que su parte no tuvo intervención alguna (ver fs. 109 vta.), por lo que mal puede incorporarse y acreditar ningún hecho en este proceso porque no fue ratificada por el testigo ni se tuvo posibilidad de controlar su declaración, lo que conculca su derecho de defensa.

Le llama la atención que, entre las fotocopias presentadas como prueba por la demandada (fs. 88/206) no se encuentra la declaración íntegra del Sr. Fombella y tampoco pudo ser encontrado el expediente "Sanmartino c. Vázquez-Desalojo" en el juzgado de 25° Nom. C. y C (ver certificado de fs. 63).

Tercer Agravio: Reitera lo dicho respecto al boleto de compraventa celebrado entre la Sra. Vázquez y Fombella (fs. 20), alegando que no puede tenerse por cierta la posesión de la demandada en base a este documento habida cuenta que carece de autenticidad y fecha cierta con lo cual tampoco puede acreditar la certeza de dicho hecho.

Dice que, conforme al art. 1035 C.C. la fecha cierta será "la de su exhibición en juicio...". En este sentido, afirma que la presentación del boleto en un proceso judicial no puede establecerse con certeza. Parece que se presentó por primera vez en autos "Sanmartino Aldo José c. Elsa Alicia Vázquez-Desalojo", tramitados en 25° Civil, no pudiéndose precisar con certeza la fecha exacta ya que el expediente, pese a ser ofrecido, no ha sido encontrado (fs. 63), mas de la sentencia de la Cámara Séptima (fs. 106 vta.) surgiría que lo fue en 1987 y no en septiembre de 1982 (fecha del boleto).

Agrega que si bien la sentencia -fs. 280- se apoya en la declaración del testigo Fonsfría para reafirmar la certeza en el ejercicio de la posesión comprobando los

trabajos realizados en el inmueble, dicho testigo no establece la fecha a la cual se refiere (ver fs. 224 vta.), por lo que no puede considerarse que esos trabajos fueron realizados en septiembre de 1982.

Cuarto Agravio: Sostiene que la sentencia confunde el objeto entre un proceso de desalojo y uno por reivindicación. Mal puede tener por comprobada la posesión con la decisión de un proceso de desalojo donde la cuestión litigiosa no era el derecho real de dominio, sino repito, el uso y goce del bien.

La sentencia recurrida tiene por probada la posesión de la Sra. Vázquez por hechos comprobados en otros procesos en los cuales el objeto litigioso no fue la posesión sino que la accionada hizo valer su pretendido derecho posesorio, pero no se juzgó su posesión. Sin embargo, la sentencia tiene por cierta la posesión conforme esas decisiones que ni siquiera las examinaron respecto a las pruebas obrantes en este expediente.

Quinto Agravio: Critica el decisorio toda vez que se computa el plazo a los fines de la prescripción adquisitiva desde la fecha del boleto referido, lo cual no es posible en razón de carecer de fecha cierta, por lo que el cálculo efectuado -casi 17 años desde sept. De 1982 hasta el 31/8/99- carece de toda fundamentación fáctica y legal; el verdadero cómputo debe realizarse desde la sentencia de la Cámara Séptima, es decir, desde el 12/11/97 hasta el 31/8/99: 11 años y ocho

meses, sin unirse la posesión de Fombella porque transmitió por escritura pública a Sanmartino la posesión, por lo que no transcurrió, pues, el plazo legal prevenido en el art. 4016 C.C.

Sexto Agravio: El recurrente no comparte la postura del a-quo, en cuanto considera que la Sra. Vázquez unió su posesión a la de Fombella de conformidad a lo dispuesto por el art. 4005 C.C. toda vez que la condición para poder sumar ambas posesiones reside, precisamente, en que las dos sean de buena fe, que se ligen inmediatamente sin haber intercalado posesión de mala fe y que lo sean por un vínculo de derecho.

En tal sentido, considera que no puede invocarse buena fe cuando la demandada, el 15/10/82 (fs. 52 y 65) conocía que la posesión del inmueble fue transferida del Sr. Fombella al Sr. Sanmartino, como fue reconocido al absolver posiciones a fs. 243.

Entonces -dice- si la demandada reconoció que el Sr. Sanmartino tuvo la posesión y no ella, no tiene buena fe cuando afirma que posee desde septiembre de 1982 ya que no fue exclusiva señora de la cosa.

La demandada intervierte su título recién en 1987, como lo declaró al absolver posiciones, en el proceso de desalojo "Sanmartino c. Vázquez", decidido en la sentencia de la Cámara Séptima.

Entiende que, para el supuesto hipotético que se considerase que tuviera valor la fecha del boleto -lo que niega- posteriormente el 15/10/82, según escritura pública, se le entregó la posesión al Sr. Sanmartino, por lo que la Sra. Vázquez no poseyó a título de dueña inmediatamente de Fombella.

Dice que tampoco se acreditó el último requisito, necesario para la accesión de posesiones, esto es, que lo sean por un vínculo de derecho ya que el boleto de compraventa de fs. 20 no es auténtico y por escritura pública.

Séptimo Agravio: Resiste el pronunciamiento en cuanto decide que la demandada ha adquirido la propiedad del bien por el transcurso del tiempo en el ejercicio de buena fe de la finca, ya que la accionada es poseedora de mala fe ya que recién exterioriza su voluntad como poseedora por si misma en el primer proceso de desalojo ("Sanmartino c. Vázquez") durante el año 1987. Puede haber sucedido - señala- que la accionada habitara el inmueble cuando convivió con Sanmartino, no por derecho propio y, luego, cambia su voluntad posesoria durante el proceso de desalojo, vulnerando el art. 2354 que dispone que no puede cambiar por propia voluntad, ni por el transcurso del tiempo las cualidades de su posesión,

continuando como comenzó; por lo cual cuando la sentencia reconoce que adquiere la propiedad por el transcurso del tiempo, es injusta e ilegítima.

Octavo Agravio: Entiende que la sentencia interpreta que el relato de las afirmaciones de la demandada es un reconocimiento, lo cual es falso.

Dice que el juzgador tiene por cierto que su parte reconoció que la demandada es poseedora -aunque de mala fe-, cuando en realidad solamente describió las manifestaciones de la accionada sin que ello importara reconocimiento alguno de sus derechos posesorios que fueron y siguen siendo negados enfáticamente.

Reitera que, como actor en esta acción de reivindicación, inicia la misma como propietario que carece de la posesión del bien en contra de la demandada que lo detenta. Pero ello, de ninguna manera puede ser interpretado como un reconocimiento de los derechos posesorios de la demandada.

A fs. 306/312, contesta los agravios la parte demandada y, a base de las argumentaciones que expresa pide el rechazo de la apelación, con costas, y adhiere al recurso de apelación deducido por la actora, expresando los agravios que le provoca la resolución en crisis (fs. 313/315).

IV) Agravios de la demandada: La accionada se agravia toda vez que la a quo, al abordar la defensa de "sine actione agit", admite que el actor no tiene la posesión de los derechos y acciones adquiridas por subasta pública pero considera irrelevante "el hecho de que el actor se encuentre o no, en ejercicio de la posesión o haya perdido la misma o nunca la hubiere ejercido", por lo que entiende que se encuentra suficientemente legitimado para promover la acción reivindicatoria.

Dice que el sentenciante se apoya en la doctrina de Lafaille, y se aferra al hecho de que siendo el accionante condómino, resulta aplicable lo dispuesto por el art. 2679 C.C., olvidando que tanto éste como sus antecesores, jamás tuvieron la posesión, a pesar de que el Dr. R., en el escrito introductivo de demanda (fs. 11/13) sostiene lo contrario "Que en la reivindicación, quien presenta título de propiedad, remontándose hasta alguno que es anterior a la posesión del demandado, vence en la acción, ya que las escrituras que acreditan el dominio de sus antecesores, hacen presumir que éstos tuvieron la posesión y lo autorizan a accionar en su propio interés" (fs. 12, puntos 3.1. y 3.2).

Dice que, en los autos "Bizzochi c. Cangiano-Desalojo" se denegó la posesión que reclamó al Dr. Renella. Señala que, presumiblemente el Inferior entendió que, ya sea el título del reivindicante, anterior o posterior a la posesión de la accionada, puede en principio, invocar la presumida posesión de todos sus antecesores y no sólo la de su autor inmediato, presunción que, puede ser destruida por la actual

poseedora. De esa manera, considera que está acabadamente probado que ni el Dr. Renella ni sus antecesores en su título tuvieron la posesión. Al actor se la denegó el juez de 2° Nom. C. Y C. y esa resolución fue consentida por él (ver fs. 34/35 autos Bizzochi c. Cangiano").

A su antecesora, Srta. Alejandra Cangiano, jamás se le hizo tradición de esos derecho y acciones. Tan es así que al absolver posiciones in re "Cangiano Alejandra E. y otra c. Elsa Alicia Vázquez-Desalojo", al responder a la 2da. Preg. (fs. 158) dijo "Que es cierto en lo que respecta a ella (acta de fs. 159); y al hacerlo como testigo en autos, al contestar la 6° preg. dijo "que nunca ingresó al inmueble que le fue donado; que no sabe como es" (acta de fs. 224).

Agrega que, Alfredo Sanmartino -padre de Orlando Alfredo Sanmartino-, tampoco detentó la posesión del inmueble porque su hijo tampoco la tuvo, si se repara que su antecesor Edgard Ignacio Fombella, le hizo tradición del mismo a la demandada Elsa Alicia Vázquez. El nombrado en primer término, jamás pudo obtener la posesión porque el vendedor, con anterioridad (20/09/1982), mediante boleto privado de compraventa, le vendió a la demandada el inmueble de que se trata, percibió el precio y le hizo tradición de lo vendido.

Si al Dr. Renella y a sus antecesores no se les hizo tradición de los derechos y acciones, resulta claro la falta de acción para promover el petitorio. El ciclo que

arranca del actor y se retrotrae a los años anteriores se interrumpe en Alfredo Orlando Sanmartino, a quien el Sr. Fombella, jamás le otorgó la posesión. El demandante no ha probado su derecho a poseer y menos aún la de sus antecesores.

Solicita, en definitiva, se revoque el decisorio en la forma solicita y se haga lugar a la defensa de falta de acción opuesta.

A fs. 316/319 contesta el traslado la parte actora quien solicita el rechazo de la vía recursiva en los términos que da cuenta su responde.

V) Análisis del recurso deducido por la demandada:

En primer lugar, corresponde analizar la procedencia formal del recurso de apelación interpuesto por la demandada. En este sentido nuestro más alto cuerpo tiene entendido que el Tribunal de Alzada tiene tres oportunidades para pronunciarse al respecto: a) de oficio antes del primer decreto de tramitación; b) a petición del apelado formulada en tiempo hábil y resuelta en juicio verbal y c) de oficio o a petición de parte, al dictar la sentencia definitiva (TSJ Cba., sala C. y C. 8/05/98 in re "De Vrient de Von Rennemkzpff - Lía", LLC, 1999-65).

Al respecto, la Doctrina es conteste en entender que existen presupuestos subjetivos y objetivos de admisibilidad del recurso. Dentro de los primeros

tenemos: a) existencia de agravio o interés; b) legitimación del recurrente y c) competencia del tribunal revisor.

En la especie, no se observa el cumplimiento del primero de los recaudos mencionados. En efecto, el concepto de "agravio" importa la lesión, la injusticia, la ofensa, el perjuicio material o moral sufrimiento por el litigante derrotado, total o parcialmente, en una resolución judicial, y a la cual imputaba, por tanto, contener un vicio, ya fuera en la apreciación de los hechos como en la aplicación del derecho, o en el procedimiento de su construcción. Concretamente, sólo alcanza para que exista agravio "el mero vencimiento de las expectativas que tenía la parte con respecto a la pretensión por ella deducida en ese juicio. Es lo que los autores portugueses denominan sucumbencia" (conf. Bacre, Recursos Ordinarios y Extraordinarios, p. 129).

En tal sentido, no se atisban en la especie, agravio alguno infringido por el decisorio a la demandada (arg. art. 354, CPC) toda vez que ésta resulta vencedora en la contienda, habiéndose hecho lugar a su pretensión; es decir, al rechazo de la demanda de reivindicación incoada por la contraria. No puede recurrir, por más que esté legitimada para hacerlo, la parte que ha sido satisfecha totalmente en su pretensión, aunque invoque discrepancia con algún fundamento jurídico del fallo. El agravio causado debe ser cierto, no meramente potencial o académico, por lo

que el interés privado debe ser el motor que ponga en funcionamiento la actividad impugnativa.

Dicho de otro modo, debe existir una lesión que debe ser del interés del impugnante. A la luz de esta consideración se ha expresado que "el interés para recurrir se configura cuando un sujeto se encuentra en una situación más desfavorable de la que tenía antes del dictado de una resolución judicial" (Tesone, Alberto José, "En torno a la legitimación para recurrir", p 299 en "La legitimación. Homenaje al Prof. Dr. Lino E. Palacio", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1996), situación que no se vislumbra en el sublite, razón por lo corresponde declarar la inadmisibilidad formal de la vía recursiva deducida por la Sra. Vázquez por falta de uno de los presupuestos subjetivos mencionados (agravio).

Ahora bien, conforme lo dispuesto por nuestra compilación adjetiva, la sentencia de Segunda Instancia sólo "... podrá recaer sobre puntos que hubieren sido sometidos a juicio en la primera instancia" (art. 332), sin embargo corresponde destacar que no necesariamente deben haber sido resueltos todos los puntos litigiosos, para que ellos integren la competencia de Cámara.

En efecto, al haberse pronunciado el a quo a favor de la prescripción adquisitiva no era necesario que decidiera sobre la procedencia o no de la excepción de falta de acción también opuesta por la demandada. Sin embargo, en el supuesto de no

compartir este Tribunal el criterio mantenido por el juzgador respecto a la excepción de prescripción, sería necesario que resolviera las restantes pretensiones y defensas deducidas en primera instancia, avanzando en la solución del entuerto, aún cuando el sentenciante no se haya pronunciado sobre ese tracto del litigio o lo haya hecho en forma desfavorable.

Conforme lo dispone el párrafo segundo de la norma citada las cuestiones propuestas por las partes, no tratadas en primera instancia, quedan automáticamente sometidas al tribunal de alzada ante la apelación del vencido.

Lo fundamental radica en la posibilidad que hayan tenido las partes de alegar y probar sobre los diversos capítulos litigiosos a los fines que puedan ser considerados por el Tribunal de alzada y no que el a quo haya resuelto todos.

Lo dicho significa que no ha menester reenviar la causa al Juzgado de origen para que, en caso de arribarse a una solución contraria a la dispuesta en primera instancia respecto a la excepción de prescripción opuesta, se pronuncie sobre las demás cuestiones no tratadas anteriormente o que le fueren adversas, en razón de un principio de economía procesal, correspondiendo que este Tribunal se pronuncie por primera vez sobre los puntos referidos antes omitidos o denegados.

Conforme lo dicho precedentemente, corresponde, pues, adentrarnos al estudio del recurso de apelación deducido por la parte actora, debiendo tratarse, en su caso, todos los puntos sometidos a decisión del a-quo en la sede anterior.

VI) Análisis de los Agravios de la Actora: Entrando a analizar los agravios esgrimidos por la parte actora y, luego de analizada la prueba arrimada, soy de la opinión que el recurso debe prosperar por las razones que paso a exponer: Antes que nada, corresponde destacar que, la acción reivindicatoria, es la que se confiere a quien, afirmándose titular de un derecho real con derecho a poseer (*ius posidendi*) pretende, ante el desconocimiento de su derecho, la declaración de certeza del mismo y la entrega de la cosa consecuente o simplemente lo segundo si no mediara desconocimiento.

Ahora bien, al tratarse de un juicio petitorio, donde lo debatido es el derecho, es fundamental que el accionante demuestre la causa fuente de su derecho a poseer, es decir, el título, que deberá consistir en una adquisición efectuada por compra, donación, permuta u otros medios que, por su naturaleza, sirven para pasar de una persona a otra la propiedad de una cosa, ya sean celebrados éstos mediante escritura pública o subasta judicial, en virtud de tratarse de la transferencia de un inmueble (conf. art. 1184, C.C.).

En síntesis, el reivindicante no podrá triunfar en la contienda si no presenta título alguno aunque el poseedor no esgrima alguno (conf. Musto, Néstor Jorge "Derechos Reales", t. IV, p. 361). Como ya veremos seguidamente, tal extremo ha sido debidamente acreditado, razón por lo cual la demanda intentada debe prosperar.

En efecto, conforme consta del informe del Registro General de Propiedad obrante a fs. 78/80, el accionante adquirió la nuda propiedad de los derechos y acciones indivisos equivalentes al 62,50% del lote objeto de demanda, por adjudicación en subasta pública, en los autos "Bizzochi Héctor Fernando c. Cangiano Raúl Roberto-Desalojo" del Juzgado de Primera Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, por auto nro. 540 de fecha 21/09/97 y nro. 66 del 22/11/99, inscripta en forma definitiva con fecha 31/05/99. El accionante ha acreditado, entonces, que tiene título sobre la cosa, es decir, el antecedente jurídico del cual resulta el derecho ejercitado.

Ahora bien, la posesión de la demandada, Sra. Vázquez, es anterior a la fecha de la subasta referida, conforme surge del auto N° 186 de fecha 24/03/99 dictado en los autos citados ("Bizzochi..." fs. 34/35), lo que significa que el demandante no fue puesto en posesión del inmueble de marras.

Al respecto, y sólo entrando a dilucidar el tema referido a la legitimación para demandar y no a la cuestión de fondo, es decir, sobre la procedencia de la reivindicación, entendemos que el adquirente (actor) que goza de un título perfecto, aún en el supuesto en que no se le hubiese efectuado la tradición de la cosa, puede no obstante ello, ejercer la reivindicación con éxito, conforme lo pone de manifiesto el a quo. El art. 2789 C.C. establece que "Si el título del reivindicante que probase su derecho a poseer la cosa fuese posterior a la posesión que tiene el demandado, aunque éste no presente título alguno, no es suficiente para fundar la demanda". Es obvia la alusión de la norma por cuanto si el título del reivindicante es posterior a la posesión del demandado, ello implica que no pudo hacérsele tradición de la cosa, por inexistencia de "posesión vacua" en los términos del art. 2383 Cod. Civ. y, por consiguiente, que no adquirió el derecho real (art. 577 cod. Cit.), ya que no pueden coexistir dos posesiones iguales sobre una misma cosa (art. 2401). Sin embargo, el artículo no establece que el actor, en tal situación, pierde irremisiblemente el juicio, sino tan sólo, que su título "no es suficiente para fundar la demanda". Para comprender tal dispositivo es menester recurrir a la fuente (Pothier, Oeuvres, t. IX), que ante el supuesto, considera el título presentado insuficiente por si mismo, para fundar la acción "... a menos que no agregue otros más antiguos capaces de justificar que el vendedor o donante de quien recibí la heredad según el contrato invocado era efectivamente dueño de ella". De modo tal que el pleito lo perderá el reivindicante con título posterior a la posesión si invoca solamente su título, pero no si agrega los títulos de los sucesivos antecesores hasta

llegar a alguno que sea de fecha anterior a la posesión del demandado, en cuyo caso, el supuesto caerá dentro de la previsión del artículo siguiente (art. 2790).

La agregación de que hablamos aparece autorizada por el art. 2790, que habla de "títulos de propiedad" anterior, utilizando la expresión "títulos" en plural, interpretado a la luz de su fuente, y en la cesibilidad de la acción reivindicatoria - arts. 1444 y notas a los arts. 1445 y 2109, C.C.- de modo que en tal supuesto, el actor hace suyo el derecho a reivindicar que competía al antecesor con título anterior a la posesión del demandado y puede accionar, ya sea a nombre del antiguo propietario -como procurator in rem suam- o a nombre propio, como cesionario, puesto que, en cada una de las sucesivas transmisiones, se ha transmitido el derecho de reivindicar (conf. Mariani de Vidal, "Curso de Derechos Reales", t. 3, p. 218 y sigtes.).

La doctrina interpretativa es conteste en señalar que la fuente del art. 2789 C.C., en que funda su pretensión el apelante, en cuanto establece que el título del reivindicante que fuese posterior a la posesión que tiene el demandado no es suficiente para fundar la demanda, es obra de Pothier, quien no niega en forma absoluta la procedencia de la acción cuando el título es posterior a la posesión, siempre que, de los antecedentes inmediatos, se desprenda que el enajenante, de quien emana el título, resultaba ser el efectivo dueño de la cosa. Es decir que el demandante que no ha sido poseedor debe acreditar entonces la posesión en algún

antecedente, lo que será más dificultoso cuando más antiguo sea dicho antecedente.

Así se ha resuelto que "El sucesor singular del titular del dominio, puede reivindicar la cosa cuando ésta se encuentre poseída por un tercero, aunque no haya tenido personalmente su posesión, invocando al efecto la que tuvieron sus antecesores". (T.S.J, de Chubut, sala civil, sent.44, 11/12/1974 "in re": "Suc. de Terenzi, Domingo c. Peláez, Alfredo s/Reivindicación -Ordinario-"). En resumen, si el actor presenta con su título de propiedad, los de aquellos que le precedieron hasta remontarse a uno que sea anterior a la posesión del demandado, está autorizado para reivindicar, aunque él no haya sido nunca poseedor, pues las escrituras que acreditan el dominio de sus antecesores hacen presumir que tuvieron la posesión, y lo facultan para accionar en su propio interés, aunque no medie cesión expresa de la acción, porque ella va implícita en cada acto de enajenación (conf. Cám. De Apel. De Sgo. Del Estero, sala 2, sent.11/6/95 in re "Bulacio Ricardo A. c. Maria Josefa Paz-s/Reivindicación; idem C. 6ª C. y C., fallo citado).

En la especie, el actor presenta con su título de propiedad, los de aquellos que le precedieron hasta remontarse a uno que es anterior a la posesión del demandado. En efecto, el reivindicante adquiere en pública subasta los derechos y acciones que sobre el inmueble en litigio tenía la Sra. Alejandra Elizabeth Cangiano, conforme donación que le hiciera el titular registral del dominio, Sr. Alfredo Sanmartino,

mediante escritura pública nro. 144 de fecha 13/08/91, labrada por la Escribana Ana Isabel Pilo de Montbrun, adscripta al Registro N° 637 (ver escritura de fs. 76/77), constatado en el informe registral (fs. 80 vta.).

A su vez, al Sr. Alfredo Sanmartino le corresponden derechos y acciones sobre el inmueble de marras, por adjudicación que se le hizo -"mortis causae"- en el juicio sucesorio de su hijo, el señor Alfredo Orlando Sanmartino, de quien fue declarado único y universal heredero con la Sra. Hilda del Valle Grenetier de Sanmartino, por auto nro. 123 de fecha 29/05/85, dictado por el Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación C. y C., habiéndose aprobado las operaciones de inventario, avalúo y partición por auto nro. 392 de fecha 30/12/85, dictado por el mismo Tribunal, inscribiéndose con relación a la matrícula N° 57.400 del dpto. Capital (fs. 81 vta.).

A su vez, al Sr. Alfredo Orlando Sanmartino, le correspondió el inmueble, por compra que realizara al Sr. Edgard Ignacio Fombella mediante escritura N° 49 de fecha 15/10/82, labrada por la Escribana R. De Saiz, Adscripta al Reg. 415, inscripto definitivamente en el Registro de la Propiedad Inmueble con relación a la Matrícula 57.400 el día 26/01/83 (fs. 52/54, fs.137/139 vta. Y fs. 80), siendo las partes coincidentes en entender que fue éste quien gozaba de un dominio pleno, toda vez que tuvo, tanto el título de propiedad como la posesión del inmueble.

Lo dicho debiera ser suficiente para acoger la pretensión intentada toda vez que el título y posesión de los antecesores del Dr. Héctor Eduardo Renella tienen un título anterior a la posesión de la demandada. La prueba acompañada nos permite remontarnos a su titular anterior, es decir, al Sr. Edgard Ignacio Fombella. (en este sentido: C6ªCyC Cba. "in re": "García Sagues Alejandro c. Soc. Coop. de Servicios Públicos Laprida Limitada-Ordinario", sent. n°45 de fecha 9/04/01; ídem: C7ªCyC de Cba., sent. 36 del 6/5/97 "in re": "Rua de Mesner, Margarita c. Dora Marquez - Reivindicación"; ídem "CCC Bell Ville 22/6/93, sent. 27 "in re": "Viale Luis E. c. Mario Domini-Dda.Reivindicación").

De lo hasta aquí dicho, se concluye que, el título, no se encuentra constituido solo por la escritura o instrumento de adquisición del reivindicante, sino que se forma con ella y sus antecesores en el dominio, o sea que se presume que el reivindicante que presenta título de dominio ha poseído desde la fecha del mismo por sí o por sus antecesores, si el demandado no prueba que su posesión es anterior al origen del mismo o que ha adquirido por prescripción.

Ahora bien, el a quo, pese a mantener la doctrina citada, considera que dicha "presunción" ha sido ampliamente rebatida por la prueba arrimada al proceso. El juzgador sostiene que la demandada, Sra. Vázquez, ejerce la posesión del inmueble objeto de litigio desde septiembre de 1982 según se desprende de la declaración testimonial del Sr. Edgar I. Fombella, anterior titular registral del bien raíz, con

motivo de una compraventa plasmada en instrumento privado (boleto de compraventa) que, en copia, obra a fs. 20 de autos, siendo así reconocido por la Cámara 7ª in re "Sanmartino Aldo José y otra c. Elsa Alicia Vázquez-Desalojo", sent. Nro. 220 de fecha 12/11/87 (fs. 106/111) y por la Cámara 2da. "in re": "Cangiano Alejandra y otra c/ Elsa Alicia Vázquez y otra-Desalojo (tenencia precaria)", sent. Nro. 74 de fecha 29.09.93, fs. 198/206). El sentenciante sostiene que la Sra. Vázquez, hasta el momento de interposición de la demanda (31/08/99) detentó la posesión del inmueble de calle Copiapó por un período de casi 17 años, lo cual no resulta suficiente para adquirir el dominio por prescripción; pero, utilizando el recurso legal de la accesión de posesiones (art. 4005, C.C.), que permite considerar unidas las posesiones del actual poseedor y la de quien se la transmitiere, se desprende que la demandada cumplió con el requisito de la posesión por el término de veinte años que estipula la compilación sustantiva (art. 4015) para que pase a convertirse en "dominus" y no ya en simple poseedora, ya que el Sr. Fombella -transmitente de la posesión a Vázquez- poseía el inmueble, con motivo de titularidad dominial, desde el año 1977, a tenor de las constancias registrales que lucen a fs. 78/81, excediendo ambas posesiones sumadas, los veinte años que requiere la legislación de fondo.

Concluye de esta manera -el inferior- que, el derecho así declarado, respecto a la Sra. Vázquez, en relación al inmueble en cuestión, es de mayor jerarquía que

cualquier otro que un particular pueda esgrimir sobre el mismo y, por ende, repele la acción aquí intentada por el Dr. Renella.

Al respecto, debo advertir, que no comparto la postura asumida por el a-quo. Doy motivos: En primer lugar, el juzgador tiene por cierto la posesión de la Sra. Vázquez desde septiembre de 1982, fundado en el boleto de compraventa presentado por la demandada, entre el Sr. Fombella y la Sra. Vázquez, reconocido a través de la testimonial correspondiente del primero de los nombrados, en el juicio de desalojo antes referido ("Sanmartino...") y lo dispuesto por la Cámara Segunda y Séptima en tal sentido.

Sobre el particular, cuadra destacar que, no puede tenerse por acreditada en forma indubitable la posesión del inmueble desde la fecha señalada en el boleto de compraventa (20/09/82) por el mero reconocimiento efectuado por el enajenante - Sr. Fombella- en dicho juicio sumario. La jurisprudencia es conteste en entender en tal sentido que "...resulta excluido del juicio de desalojo el debate relativo a la naturaleza de la posesión, ya que la sentencia que se dicte en aquel no hace cosa juzgada sobre el punto" (CCC Bell Ville, 24.08.94, Sem. Jur. 1062; C.4ª C.C. Cba., 5/5/98 "in re": "Apeco S.A. c. Sessa Miguel A.", Sem. Jur. 1225, t. 80, p. 99).

En efecto, la prueba rendida en las causas citadas -desalojos- sólo puede llevar a sostener que la demandada acreditó "prima facie" la verosimilitud del derecho

invocado pero de ninguna manera acredita en forma acabada que la posesión haya sido entregada a la Sra. Vázquez en la forma y fecha referidas, pues como el mismo fallo aludido por el juzgador -y la demandada- sostiene que "... el mejor derecho a poseer y la posesión misma es materia cuya discusión trasciende la orbita propia de este procedimiento sumario, que se da cuando surge diáfano el derecho de la actora..." (sent. Nro. 220 in re "Sanmartino..." fs. 109), para concluir diciendo que "... En el sub estudio considero que existen elementos lo suficientemente idóneos como para amparar la pretensión de la demandada de que se la mantenga en el inmueble, en tanto los actores no hagan valer sus derechos a través de las acciones petitorias o posesorias que les pudieran en derecho corresponder" (fs. 109 vta.).

En segundo lugar, si bien la cláusula tercera de dicho instrumento establece que le fue entregada la posesión del inmueble a la demandada, nuestra compilación sustantiva dispone que "La sola declaración del tradente de darse por desposeído, o de dar al adquirente la posesión de la cosa, no suple las formas legales" (art. 2378), que en todo caso puede tener valor entre partes pero no frente a terceros. La tradición impone como "forma legal", la realización de actos materiales suficientemente acreditados, lo que importa desestimar toda eficacia, a los fines de acreditar la efectiva tradición del bien, lo consignado en dicho instrumento. El título válido para adquirir la posesión sólo da derecho a la posesión pero no la posesión misma.

Conforme lo expresado, la demandada debió producir en la presente causa -que es el ámbito adecuado para debatir lo relativo a la naturaleza de la posesión- prueba idónea para acreditar en forma indubitable la posesión del inmueble desde la fecha señalada, lo que no se vislumbra de la prueba arrimada.

En tercer lugar, a fs. 52/54, consta la escritura pública celebrada entre el Sr. Fombella y Alfredo Orlando Sanmartino (pareja de la demandada, ver fs. 140), mediante la cual el primero vende el inmueble en litigio a éste último, haciéndose constar que recibió el dinero con anterioridad de manos del comprador, y en su mérito "...transmite a favor del adquirente todos sus derechos de propiedad, posesión, dominio y cualquier otro que sobre lo enajenado pudiera tener o corresponderle", acto del cual tiene absoluto conocimiento la demandada, Sra. Vázquez, en razón de haber estado presente en dicha venta, conforme lo confiesa en forma expresa la accionada y surge de la prueba arrimada por la misma (fs. 21), más allá de haberse tomado razón en el Registro de la Propiedad Inmueble (26/01/83, fs. 80) y no controvierte lo actuado y manifestado por ante la escribana actuante. Tal prueba resulta suficiente para tener por cierto que la posesión del bien fue entregada por Fombella al Sr. Sanmartino.

Si bien es cierto que la cláusula de la escritura según la cual se transfieren al adquirente todos los derechos de posesión y dominio que a lo vendido tenía, no supone la existencia material del hecho -de la entrega- frente a terceros (conf. arts.

2378 y 2380), no lo es menos que tiene plena validez entre partes -comprador y vendedor- y frente a terceros que intervinieron en el acto, tal como sucede en el sublite, donde la Sra. Vázquez estuvo presente ante la actuario, en oportunidad de otorgarse la correspondiente escritura traslativa de dominio al Sr. Sanmartino.

En definitiva, considero que el actor reivindicante, si bien no fue puesto en posesión del inmueble en el momento de su adquisición -subasta pública- y, por consiguiente, no adquirió el derecho real (art. 577 C.C.), sin embargo agregó los títulos de los sucesivos antecesores hasta llegar a uno de fecha anterior a la posesión de la demandada Sra. Vázquez, es decir, la del Sr. Fombella quien, contrariamente a lo considerado por el a-quo, efectuó la tradición del bien raíz en litigio al Sr. Alfredo Orlando Sanmartino en oportunidad de otorgar la escritura pública traslativa de dominio en presencia de la demandada (fs. 137/139), debiendo entonces triunfar en su reivindicación, conforme lo disponen los arts. 2789, 2790 C.C.

Corresponde destacar que si bien ha quedado acreditado que, al momento de incoarse la presente demanda, la posesión se encontraba en manos de la demandada, conforme surge por ejemplo de los autos "Bizzochi Héctor c. Cangiano Raul Roberto-Desalojo", Auto Nro. 183 del 24/03/99, fs. 34/35, ello no significa "per se" que lo haya sido con antelación a la del Sr. Sanmartino, y desde la fecha señalada en el boleto de fs. 20 por las razones señaladas supra. Recuérdese

que la Sra. Vázquez convivía con el Sr. Alfredo O. Sanmartino y cohabitó el inmueble de marras (ver confesional de la demandada fs. 140), revistiendo el mero carácter de tenedora y, producido el fallecimiento de este último, nada impidió que "intervirtiera" el título de su posesión (art. 2353 C.C.). Es más, la propia demandada, Sra. Vázquez, confiesa, al absolver posiciones in re "Cangiano Alejandra y otra c/ Elsa Alicia Vázquez y otra-Desalojo" que recién a partir de la sentencia dictada en el juicio de desalojo que le iniciaran Aldo José Sanmartino e Hilda Grenetier (con fecha 12/11/87, fs. 106) "... se consideró con derecho a edificar y así lo hizo construyendo en la parte alta un departamento completo..." (fs. 140, 7ª posic.), lo que significa que antes de dicha fecha carecía de animus domini y luego de dicho episodio se creyó con derecho de tener la cosa bajo su poder "con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad" (conf. art. 2351 C.C.), y no antes, produciéndose a partir de allí la "interversión" del título en los términos del art. 2353.

Al respecto, destacada Doctrina ha dicho que, "... Tampoco constituye obstáculo para que alguien que tenga la cosa por un título, exteriorizando claramente su voluntad de ocupar o usurpar la cosa, desconociendo los derechos del poseedor y en forma unilateral "intervierta el título. En tal sentido expresa el art. 2458 "Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor, manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y cuando sus actos producen ese efecto". Estos actos y estas consecuencias son los

que técnicamente se denominan "interversión del título". En este caso se produce una nueva causa de la posesión, que no será el anterior arrendamiento o comodato, sino la nueva ocupación o usurpación concluyentemente exteriorizada. Para que exista interversión del título, no bastan las simples manifestaciones de la voluntad, como se desprende de la norma del art. 2447, sino que la actitud debe consistir en hechos exteriores que impliquen una verdadera contradicción a los derechos del propietario, un verdadero alzamiento contra su derecho, que puede revestir la forma judicial, aunque no es necesario que se plantee un litigio o actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de su derecho. Estos actos, por lo tanto, deben revestir un carácter ostensible e inequívoco para tener la consecuencia que la interversión apareja, cual es la de convertir la tenencia en posesión". (conf. Musto, Nestor Jorge; Derechos Reales, t. I, p. 213/4).

En el sublite, adviértase que, conforme lo confiesa la propia demandada, a partir de la resolución dictada en el juicio de desalojo referido tiene intención de someter el inmueble a un derecho de propiedad. Sin embargo, para mudar la causa de la posesión, no basta una simple declaración de voluntad o una simple intención sino que para que la interversión de título se produzca, es necesario que el tenedor -Sra. Vázquez- manifieste tal actitud "por actos exteriores" que tengan el efecto de privar al poseedor de disponer de la cosa (conf. ST Misiones, sala II, 19/05/69, Rep. La Ley, XXX, 1319, sum. 7, Capel. CC Rosario, sala II, 26/07/69, Rep. La Ley XXX, 1319, sum.6). Es menester que el tenedor realice un acto positivo de

voluntad que revele el propósito de contradecir la posesión de aquél en cuyo nombre se tenía la cosa. En este sentido, tales actos positivos exteriores consisten en la construcción que realizó en la parte alta del departamento (ver confesional, fs. 140 vta., 7ª pos.), conteste con lo declarado por el Sr. Fonsfría (fs. 224 vta. preg. 3ª), quien trabajó para la Sra. Vázquez y testifica que "En planta alta hizo un departamento con baño, pisos, paredes, techo de hormigón, tejas coloniales..." y que "... también hizo refacciones en la planta baja, en la cochera, en cerámicos" (preg. 4ª). Cuadra advertir que, si bien no precisa fecha, ello sucedió, obviamente, con posterioridad al dictado de la sentencia dictada en dicha causa, como expresa la propia demandada.

Lo dicho resulta suficiente para acoger el recurso y desestimar la excepción de prescripción adquisitiva opuesta por la demandada toda vez que no puede "acceder" su posesión a la del Sr. Fombella, toda vez que para que dos posesiones puedan unirse es necesario que no sean viciosas y que una derive de la otra, lo que no sucede en autos (arts. 2475 y 2476 C.C.; ver nota. Molitor), al no estar ligadas ambas en forma inmediata, ya que, entre ambos, existió la posesión de Alfredo O. Sanmartino (ver escritura de fs. 52 -como ya vimos-, habiendo adquirido la demandada, Elsa Alicia Vázquez, la posesión del inmueble, no por entrega efectuada por el Sr. Fombella como afirma el a-quo, sino por haber "intervertido" unilateralmente el título en los términos del art. 2353 C.C en la forma referida supra.- Tampoco existió, entonces, una posesión continua de veinte años por parte

de la demandada, como lo previene el art. 4015 Cod. cit. (cc arts. 3999 y 3948) a los fines de la prescripción veinteñal.

Por otra parte, considero que en el caso bajo examen, se produjo la interrupción del curso de la prescripción adquisitiva, a raíz de la demanda de desalojo promovida por la antecesora del demandante, es decir, por la Sra. Alejandra Cangiano en contra de la ahora demandada Sra. Elsa Alicia Vázquez, con fecha 5/11/91. El art. 3986 establece en su primera parte que "La prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuera defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio". En este sentido la Doctrina entiende que dos son los requisitos esenciales para que esta pretensión accionable interrumpa la prescripción: 1) debe ser deducida ante los órganos jurisdiccionales; 2) debe demostrar inequívocamente la voluntad de lograr la restitución de la cosa (Moisset de Espanés, Luis; ED, 67-659). La demanda incoada por su antecesora, Alejandra Cangiano, cumplimentaba dichos recaudos toda vez que, la acción de desalojo tiene por efecto, precisamente, lograr la restitución de la cosa, más allá que no se haya obtenido, habiéndose rechazado la demanda, toda vez que dicha resolución no es definitiva y deja a salvo la vía ordinaria -posesorio y/o petitorio- tal como sucedió en autos. Lo importante es que el actor -y sus sucesores- en ningún momento abandonaron su derecho a recuperar el inmueble dejando de lado toda idea de perderlo.

Si bien puede decirse que la acción de desalojo fue incoada por la Sra. Cangiano (antecesora en el título) y no por el ahora demandante, debe tenerse en cuenta que, conforme lo tiene dicho destacada doctrina "... por la misma parte, se entiende no solamente las mismas personas físicas o jurídicas que intervinieron en los dos procesos, sino también los sucesores de aquéllas a título universal o singular; es el mismo criterio que la cosa juzgada..." (Devis Echandía; Compendio de pruebas judiciales; vol. 2 ptos. 88 y 89, ps. 205/206).

Ergo, en virtud de la interposición de la demanda referida, queda como no sucedida la posesión que le ha precedido y la prescripción no puede adquirirse sino en virtud de una nueva posesión (conf. art. 3998, C.C.). En efecto, la interrupción del curso de la prescripción borra toda posesión anterior y hace que la propiedad no pueda adquirirse sino iniciando una nueva posesión. La prescripción interrumpida desaparece como tal, ya que el tiempo pasado queda perdido como si no hubiera existido, de manera tal que si se reanuda el curso, debe comenzarse un nuevo cómputo por el total del tiempo necesario para usucapir (20 años). Es decir que cuando existe una causal de interrupción de la prescripción, puede comenzarse a usucapir nuevamente pero quedará inutilizado todo el tiempo cumplido antes de ocurrida la causal (conf. Elena I. Highton, Derechos Reales - Dominio y Usucapión - 2ª Parte, p. 172).

Por otra parte, no debe olvidarse que, la usucapión, es un medio excepcional de adquisición del dominio y la comprobación de los extremos exigidos por la ley debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente y conjugarse con las exigencias que se desprenden del texto de la ley.

Por las razones apuntadas precedentemente, a las cuales me remito en honor a la brevedad, corresponde también desestimar la excepción de falta de acción opuesta por la demandada toda vez que, contrariamente a lo pretendido por ésta, quedó acreditado que el actor reivindicante, si bien no fue puesto en posesión del inmueble en el momento de su adquisición -subasta pública- ni tampoco lo fue por su antecesora inmediata (Alejandra Cangiano), no obstante agregó los títulos de los sucesivos antecesores hasta llegar a uno de fecha anterior a la posesión de la demandada Sra. Vázquez, es decir, la del Sr. Fombella quien, contrariamente a lo considerado por el a-quo, efectuó la tradición del bien raíz en litigio al Sr. Alfredo Orlando Sanmartino en oportunidad de otorgar la escritura pública traslativa de dominio en presencia de la demandada (fs. 137/139), debiendo entonces triunfar en su reivindicación, conforme lo disponen los arts. 2789, 2790 C.C.

En nada empece a la conclusión arribada las manifestaciones vertidas por la accionada al contestar la demanda en el sentido que el Sr. Alfredo Sanmartino (padre del fallecido Alfredo Orlando Sanmartino quien compró el inmueble a Fombella, fs. 52) jamás pudo "donar" a la Sra. Alejandra E. Cangiano algo que ya

no era de su propiedad -bien raíz objeto de litigio- ya que con anterioridad había vendido y cedido sus derechos y acciones a la nuda propiedad a Aldo José Sanmartino, conforme da cuenta la escritura pública nro. 11 de fecha 24.01.86 autorizada por la Notaria Ana Isabel Pilo de Montbrun, titl del registro 637 (fs. 17/19). La demandada alega que el Sr. Alfredo Sanmartino tuvo la propiedad cuando vendió y cedió sus derechos a Aldo José Sanmartino pero mal pudo transmitir luego dicho bien a la Sra. Cangiano un derecho mejor o más extenso que el que gozaba (art. 3270 ibid.), por lo que dicha operación resulta nula y sin ningún valor.

No comparto la tesis recién expuesta. Doy razones: Si bien es cierto que el Sr. Alfredo Sanmartino, antes de "donar" el inmueble de marras a la Sra. Alejandra E. Cangiano mediante escritura pública de fecha 13/08/91 (fs. 18), otorgó escritura a favor de Aldo José Sanmartino, cediendo y transfiriendo la nuda propiedad de los derechos hereditarios que le correspondían en el juicio sucesorio del señor Alfredo Orlando Sanmartino, no lo es menos que, dicha "cesión" no fue nunca inscripta ni tampoco se hizo tradición alguna del inmueble, conforme lo pone de resalto la propia demandada.

En este sentido, el art. 577 C.C. es terminante al disponer que "Antes de la tradición de la cosa el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real" y el art. 3265 reza: "Todos los derechos que una persona transmite por contrato a otra persona,

sólo pasan al adquirente de esos derechos por tradición". De esta manera, cuando se celebra un contrato con el fin de transmitir un derecho real, éste viene a convertirse en el título (causa) del derecho real que para quedar constituido requerirá del modo (tradición). Esta, cuando tiene carácter constitutivo como en el caso subexamen, provoca el desplazamiento patrimonial que las partes habían propuesto realizar. No obstante, dicho desplazamiento no operó a mérito de no haberse efectuado la entrega de la posesión del bien, como ya dije, toda vez que el derecho real continúa adquiriéndose, transmittiéndose o modificándose con el título y modo. Por otra parte -reitero- el cesionario (Aldo José Sanmartino) tampoco procedió a inscribir la transferencia en el registro de la propiedad inmueble conforme lo exige el art. 2505 C.C. y art. 2 de la ley 17.801 lo que afecta la posibilidad de que su derecho se oponga a terceros interesados -vgr. Sra. Cangiano- quienes podrán actuar como si la titularidad todavía no se hubiera transferido (conf. Moisset de Espanés, Luis, La transmisión del dominio y otros derechos reales en la reforma del Código Civil, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Madrid, Año 57, n° 544, mayo-junio de 1981, sec. Estudios de Derecho Extranjero, p.397), máxime cuando ésta última (Cangiano) si procedió a inscribir su título en el registro en la forma requerida por la ley (ver fs. 80/81), fijando su prioridad respecto al adquirente de fecha anterior, Aldo Sanmartino (conf. Morello, Augusto M., ob. citada, t. II, p. 247).

Por el contrario, aunque nos colocáramos en la postura adoptada por el a quo, y entendiéramos que la Sra. Vázquez recibió la posesión del inmueble de manos del Sr. Fombella, arribaríamos a igual suerte que la relacionada precedentemente

En efecto, de ninguna manera podríamos entender que la demandada recibió la posesión del inmueble en la fecha pretendida por la demandada -y señalada por el a quo-, es decir, al otorgarse el "boleto de compraventa" de fs. 20 (20.09.82), y que la posesión de la demandada es de buena fe.

No debemos olvidar que, los instrumentos privados, aún después de reconocidos, no prueban contra terceros o contra los sucesores por título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos (conf. art. 1034, C.C.), razón por lo cual, tampoco puede tenerse por cierto que, a la Sra. Vázquez, se le hubiera entregado la posesión del inmueble en la fecha estipulada en el boleto de compraventa de fs. 20 (20/09/82) sino, en todo caso, en la "fecha cierta" adquirida por dicho boleto. Ella sería, en tal caso, la de su presentación en el juicio de desalojo referido ("Sanmartino c. Vázquez") -conf. art. 1035 C.C.- que data de varios años después (1987) al de la escritura traslativa otorgada por Fombella a Sanmartino (15/10/82).

Además, aunque tuviéramos por cierto que la Sra. Vázquez recibió la posesión del inmueble en la fecha precisada en el boleto, es decir, el 20/09/82, de ninguna manera podría reputarse que existió buena fe en la adquisición, toda vez que, la

buena fe del adquirente -Sra. Vázquez-, debe existir no sólo en el momento de la tradición sino también en el momento del contrato, debiendo considerarse dicho "momento", el de su fecha cierta y no la fijada en el boleto, como ya dije (conf. Machado, Exposición y Comentario del Código Civil Argentino, t. II, p. 304); razón por lo cual, siendo aquél (1987) posterior al de la escritura celebrada entre Fombella y Sanmartino (octubre de 1982), debe reputarse la posesión de la Sra. Vázquez, de mala fe.

De esta manera, aún en el supuesto de entender que el Sr. Fombella hubiera entregado la posesión del bien a la Sra. Vázquez, fundado en el boleto de compraventa antes aludido (fs. 20), la misma debe considerarse de mala fe, en razón de haber conocido a la fecha de su otorgamiento (fecha cierta, es decir, la de su presentación en juicio de desalojo, art. 1035 C.C.) la transmisión anterior a favor del Sr. Sanmartino, en virtud de haber estado presente en el acto de otorgamiento de la escritura pública y, más aún, sin expresar oposición en contrario a dicha transmisión. Nuestro régimen legal, ante dos personas con título, prefiere a quien primero obtuvo el modo (tradición); se trata de una clara aplicación del principio *prior in tempore potior in iure*. No interesa la fecha del título sino la de efectivización de la tradición por lo que puede triunfar aquel cuyo título es más nuevo si antes se le entregó la cosa (vgr. art. 2791, C.C.). La solución coincide con la consagrada por el art. 3269, el que establece la preferencia en la ejecución del contrato, cuando alguien hubiera contratado con varias personas la obligación de

transmitirle sus derechos sobre la misma cosa, a favor de aquella que primero hubiese sido puesta en posesión de la cosa, aunque su título fuese más reciente, pero ello a condición de tener "buena fe" cuando la cosa le fue entregada, hecho que no se vislumbra en la especie por las razones apuntadas supra.

En sentido análogo, el art. 594, aludiendo a la obligación de dar cosas ciertas con el fin de transferir derechos reales, dispone que si el deudor hubiera hecho tradición del inmueble a otro para transferirle el dominio, el acreedor tendrá acción contra terceros que hubieran tomado la posesión sabiendo que el deudor había asumido con anterioridad esa misma obligación. De esta manera, se observa que la normativa citada debe aplicarse en forma integrada y relacionándose una con otra, por lo que el triunfo de quien primero obtuvo la posesión queda "condicionada" a su buena fe, o sea, la creencia cierta de que la cosa no había sido enajenada a otra persona, lo que no se atisba en autos como ya dije, toda vez que la Sra. Vázquez, a la fecha de otorgársele el boleto de compraventa de fs. 20 -fecha cierta y no la estipulada en el boleto- conocía de la transferencia anterior existente entre Fombella y Sanmartino en razón de haber estado presente en el acto de escrituración, como ya dijimos (amén de la inscripción registral correspondiente con fecha 26/01/83, fs. 80).

Este es el temperamento sustentado por la doctrina y jurisprudencia dominante. En este sentido se ha dicho que "con prescindencia de su carácter o no de dueño, la

hermenéutica del código otorga al poseedor una protección que alcanza a "preferir" su derecho al de quien presenta escritura pública anterior, con la sola condición de buena fe (art. 2789). En toda disputa de dos o más personas respecto de un inmueble, el de la posesión de buena fe prevalece sobre todo otro derecho, salvo disposición expresa en contrario, por aplicación del principio sentado en el art. 594" (conf. Eduardo E. Moreno Dubois y Wenceslao Tejerina, LA LEY, 123-1219/1241). En igual sentido, Morello Augusto M., "El Boleto de Compraventa Inmobiliaria", t. II, p. 248/249).

La jurisprudencia al respecto ha dicho que "La posesión del inmueble adquirida cuando se conocía la existencia de otra promesa de venta precedente, y por ello sin la buena fe exigida, perjudica el derecho del poseedor respecto del adquirente precedente" (CNCiv. sala C, 26/05/97, La Ley, 1977-D, 152). Respecto a la posibilidad de usucapir en este supuesto, corresponde nos remitamos a lo ya dicho anteriormente, con relación al efecto interruptivo de la prescripción producida por la demanda de desalojo promovida por la Sra. Alejandra Cangiano en contra de la ahora demandada, Sra. Elsa Alicia Vázquez, con fecha 5/11/91, a lo cual me remito brevivatis causae.-

En este sentido doy mi voto.

El doctor Napolitano dijo:

Que adhería a lo expresado por el Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta ya que comparte los fundamentos.

El doctor Lavayen dijo:

Corresponde: 1) Declarar formalmente inadmisibile el recurso de apelación interpuesto por la demandada Elsa Alicia Vazquez; 2) Acoger el recurso de apelación deducido por el accionante, Héctor Eduardo Renella y, en consecuencia, rechazar la excepción de prescripción y la de falta de acción opuesta por la demandada y hacer lugar a la demanda reivindicatoria, debiendo la Sra. Elsa Alicia Vazquez entregar el inmueble objeto de litigio al actor en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ley; Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art. 130, CPC); diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base cierta para ello debiendo estimarse los mismos de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 29, 34, 35, 36, 37 y 62 de la ley 8226. 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en primera instancia la que deberá ajustarse al pronunciamiento que se propicia.

2ª cuestión. - El doctor Napolitano dijo:

Que adhería a lo expresado por el Vocal preopinante, y vota en igual sentido a esta cuestión propuesta ya que comparte los fundamentos.

Por el resultado de la votación que antecede y por unanimidad, atento el voto coincidente de los doctores Lavayén y Napolitano (art. 382, C.P.C., texto reformado por ley 9129), se resuelve: 1) Declarar formalmente inadmisibile el recurso de apelación interpuesto por la demandada Elsa Alicia Vazquez; 2) Acoger el recurso de apelación deducido por el accionante, Héctor Eduardo Renella y, en consecuencia, rechazar la excepción de prescripción y la de falta de acción opuesta por la demandada y hacer lugar a la demanda reivindicatoria, debiendo la Sra. Elsa Alicia Vazquez entregar el inmueble objeto de litigio al actor en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ley; Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art. 130, CPC); diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base cierta para ello, a cuyo fin se estiman los siguientes porcentajes, por las tareas desarrolladas en la Alzada: para el Dr. H. E. R. en el 35% (art. 37, C.A.) del término medio de la escala del art. 34, calculados sobre la base que resulte en definitiva; para los Dres. F. M. M., R. C. M. y J. F. en conjunto y proporción de ley, en idénticos porcentajes pero calculados sobre el 20% de aquella base (conf. art. 29 ibíd); 3) Dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en primera instancia la que deberá ajustarse al pronunciamiento que se propicia. –

Eduardo Lavayen. - Enrique P. Napolitano.